

No caso em espécie, portanto, a negativa de atendimento é também ilegítima porque viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio.

Feitas essas considerações, concluo restarem presentes o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado, requisitos exigidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.

Quanto aos demais requisitos, a saber, a existência do pedido da parte, a prova inequívoca dos fatos alegados e a fundamentação da decisão antecipatória, entendo igualmente que foram atendidos perante o Juízo de piso.

Por fim, quanto ao último requisito "inexistência do *periculum in mora* inverso" – sobre o qual a agravada alega suposta inobservância – cabe salientar que inexiste perigo de irreversibilidade na concessão da medida antecipatória, pois, em caso de julgamento de improcedência da ação originária no Juízo de piso, a demandada poderá se ressarcir dos valores despendidos em virtude da cobertura da realização da cirurgia.

Considerando todo o exposto, **CONHEÇO** e **DOU PROVIMENTO** ao presente Agravo de Instrumento, para manter *in totum* a retro Decisão Monocrática de minha lavra, mediante a qual, em apreciação de pedido de efeito suspensivo ativo, concedi a tutela de urgência pleiteada.

Belém, 13 de novembro de 2019.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora



SEGURO SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE QUE É MERAMENTE ESTÉTICA. Demonstrando os elementos dos autos que a cirurgia não se destinava a embelezamento, mas sim indicada para corrigir os malefícios criados com a situação de desconforto físico, peso excessivo sobre o pubis, empecilho à livre movimentação, dificuldade de higienização, mal estar psíquico e para prevenir doenças, não se enquadrando no elenco, trazido pelo contrato, das intervenções não abrangidas pelo seguro, é de se manter a condenação da seguradora ao ressarcimento dos valores despendidos pela segurada na cirurgia. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70003828878, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 28/10/2002).

Feitas essas considerações, vale anotar que a legislação processual civil (art. 300 do NCPC) consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório à parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A leitura dos dispositivos supra faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela está atrelada aos seguintes requisitos: a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo (inexistência do *periculum in mora* inverso).

A seu turno, o deferimento da tutela de urgência com base na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois clássicos pressupostos: o próprio risco do dano (*periculum in mora*) e a probabilidade do direito alegado (*fumus bonis iuris*), múnus esse, que recai à parte autora da ação intentada, ora agravada.

No que concerne à probabilidade do direito, **evidenciada a orientação médica quanto a necessidade de realização da CIRURGIA REPARADORA** nos termos aludidos supra, **por se revelar o único meio adequado para o trato das moléstias da paciente**, deduzo, em exame perfunctório, que a enfermidade preenche os requisitos técnicos e científicos determinativos do método de cura.

Igualmente, entendo restar demonstrada a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face ao laudo médico, que já relata histórico de depressão da jovem paciente, ocasionada por sua condição física vexatória, que lhe causa dor emocional e baixa autoestima.

Por fim, **cumprе ressaltar que a cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei nº 9.656/98, e nem está circunscrita às possibilidades de tratamento listadas nos instrumentos de regulamentação da ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.**



no intuito de obter um formato "normal" das mamas. Isto é, pretende-se, apenas, garantir à paciente menor que obtenha mamas com aspecto e características dentro da normalidade, enquadrando-se portanto, no conceito de CIRURGIA REPARADORA.

Neste sentido, colaciono os seguintes exemplares da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CORREÇÃO DE ASSIMETRIA MAMÁRIA EM MENOR - NECESSIDADE COMPROVADA - PROBLEMAS DE ORDEM FÍSICA E PSICOLÓGICA - ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO PURAMENTE ESTÉTICA AFASTADA - ACERTO - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A MÉDICO NÃO CREDENCIADO - PAGAMENTO LIMITADO PELA SEGURADORA AO QUE SE PAGARIA A UM MÉDICO CREDENCIADO - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO POR MAIORIA. (Agravado de Instrumento 219543-30012506-14.2010.8.17.0000, Rel. Antônio Fernando de Araújo Martins, 6ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2011, DJe 02/08/2011) – Destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA RESTAURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. **INTERVENÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO SEGURO**. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Havendo prova que a cirurgia requerida pela autora/consumidora não possui caráter estético e finalidade embelezadora, mas sim reparatória, deve a seguradora cobrir o procedimento. A multa diária ou astreintes não possui natureza indenizatória, compensatória ou reparatória, mas sim coercitiva, pois objetiva vencer a obstinação do devedor ao não cumprimento das obrigações. Redução da multa diária, que se revela como necessária em face do excesso, sob pena de enriquecimento sem causa. (Apelação Cível; Número do Acórdão 149291-1; Relator: Eloy D'Almeida Lins; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento 19/2/2009) – Destaquei.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. MAMOPLASTIA. COBERTURA CONTRATUAL. Hipótese em que a autora comprovou a necessidade da cirurgia plástica reparadora das mamas, por não possuir caráter estético, mas sim reparatório, impõe-se à demandada custear as despesas médicas inerentes ao procedimento, bem como os valores dos honorários médicos, estes dentro do limite contratual. Apelação desprovida." (Apelação Cível Nº 70024566457, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/07/2009) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE E IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. Não se vislumbra nulidade da sentença, uma vez que a produção das provas é uma faculdade do Juiz, na qualidade de dirigente do processo, e insita ao seu convencimento ou não. Excesso de flacidez decorrente de intervenção anterior visando a corrigir obesidade mórbida. Elementos suficientes a indicar a necessidade de a autora submeter-se a tal intervenção. Dever da recorrente de cobrir o respectivo custo por tratar-se de cirurgia plástica reparadora e não estética. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70030715502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 17/03/2010) – Destaquei.



caracterizam pelo desenvolvimento insuficiente da glândula mamária: (I) mamas tuberosas (patologia ocasionada em razão de o tecido que cobre a glândula mamária apresentar uma rigidez excessiva, o que leva a glândula a se "herniar" e se expandir pelo local de menor resistência, que é a pele fina do mamilo, causando severa deformidade), e; (II) atrofia mamária (Doença CID N64.2, caracterizada pelo desenvolvimento patológico das mamas, que pode ser uni ou bilateral).

Em pesquisa, averigui que a chamada "Mama Tuberosa" é deformidade rara, também conhecida por Mama Tubular, acometendo mulheres jovens e podendo se manifestar em uma ou ambas as mamas. Ocorre devido à presença de um tecido fibroso em forma de anel na base da mama, localizado abaixo da aréola, que não permite o correto desenvolvimento mamário durante a puberdade. Este anel fibroso impede o crescimento horizontal e vertical da mama, fazendo com que ocorra apenas o crescimento mamário em direção da aréola. Com isso a mama adota um formato tubular, com o sulco mamário posicionado mais alto que o normal e a aréola aumentada.

Cediço é que muitas mulheres portadoras dessas más-formações podem apresentar grandes desconfortos, desequilíbrios físicos e até mesmo psicológicos. E, embora o principal impacto dessas deformidades seja o estético, há uma indubitável e muito forte influência sobre a saúde psicológica dessas mulheres.

Ademais, pode ser que a mulher vivencie consequências na função mamária, apresentando problemas ao amamentar, justamente devido ao formato diferente das mamas.

No caso dos autos, em consulta ao processo de 1º grau, verifiquei pelas fotos colacionadas que existe flagrante deformação e assimetria entre as mamas da agravante, sendo a mama direita consideravelmente menor que a esquerda.

Percebo também que a presente lide envolve não apenas a questão física, mas também a desarmonia psicológica da paciente que já se sente incomodada com sua imagem corporal, tendo-se tornado reclusa e introspectiva, principalmente, por se tratar de uma jovem em formação, de 15 (quinze) anos, enfrentando um problema que lhe causa desconforto e constrangimento e que interfere, destarte, em áreas do seu desenvolvimento. Vale ressaltar que o laudo médico já relata histórico de depressão da jovem paciente.

Acerca do tema, a Revista Latino-Americana de Enfermagem traz excelente artigo no qual o Dr. Angelo do Carmo Silva Matthes, Doutor em Medicina, Professor Titular da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Barão de Mauá, esclarece:

"Uma mulher que sofre porque tem mamas grandes ou tem mamas muito pequenas certamente não tem saúde no conceito da OMS e necessita de atenção para devolver essa condição. Vale a pena lembrar que no CID-10, Classificação Internacional das Doenças, encontra-se os CIDs N64.2 e N62 para classificar a atrofia de mama e hipertrofia de mama, respectivamente, agrupadas no subgrupo de doenças das mães e, paradoxalmente, depara-se com peritos de planos de saúde que, diante de uma dessas condições, não entendem como doença e classificam a correção cirúrgica como estética e não reparadora."

Deste modo, em que pesem as alegações da agravada, não se pode considerar o procedimento em questão como puramente estético, vez que se destina à correção de deformidade severa, o que virá a garantir à jovem segura a simetria mamária e, via reflexiva, a restauração de sua autoestima e bem estar psíquico.

A cirurgia de correção da mama tuberosa e atrofiada (CIRURGIA CORRETIVA DE CÓDIGO N.º 3.06.02.033) tem como objetivo reduzir o diâmetro da aréola, baixar o sulco mamário para sua posição correta, desfazer o anel fibroso e reorganizar o tecido mamário



- (II) Que é portadora da malformação congênita denominada de "mamas tuberosas" e da patologia "atrofia mamária", Código CID N64.2, cujo tratamento envolve a cirurgia corretiva de Código n.º 3060203-3, conforme indicado pelo médico especialista (Num. 1950270 – Pág. 8);
- (III) Que tal procedimento cirúrgico é essencial para a manutenção de sua saúde física/psíquica;
- (IV) A presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal (art. 300 do NCPD), eis que a indicação médica evidencia a probabilidade do direito e o quadro de grave depressão experimentado pela agravante, advindo de sua condição de deformidade física, consubstancia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de conhecimento;
- (V) A reversibilidade da medida mediante compensação financeira caso, ao final do processo, reste demonstrada a ausência de direito da agravante;
- (VI) O entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que que, excepcionalmente, em se tratando de direito à vida e à saúde, pode o Poder Judiciário conceder tutela de urgência, independentemente de sua reversibilidade.

Ao final, rogou pela concessão do efeito suspensivo ativo para antecipar os efeitos da tutela em caráter urgente, a fim de que a agravante seja compelida a autorizar a internação e custeio do procedimento cirúrgico em questão, com o intuito de evitar maiores danos à saúde emocional, já fragilizada, da agravante.

A seu turno, a ré/agravada FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra-arrazoa alegando em síntese (Doc. Num. 2133401):

- (I) Do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência;
- (II) Ser perceptível no caso concreto, que o pleito está estritamente ligado à procedimento cirúrgico com finalidade estética;
- (I) Da ausência dos requisitos essenciais para antecipação da tutela recursal em função de não existir o direito invocado pela agravante, tendo a recusa de cobertura da cirurgia sido respaldada pelo art. 10, II e IV da Lei nº 9.656/98 (Lei reguladora dos planos e seguros privados) e pelas normas regulamentadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;
- (II) A ausência de cobertura obrigatória em procedimentos cirúrgicos com finalidade estética, que resulte em uma possível e incerta melhora da moléstia enfrentada pela agravante.

Em decisão sob o Doc. Id. Num. Num. 2033022, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, concedendo a tutela de urgência para a realização de cirurgia reparadora das mamas, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, de R\$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R\$10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

DECIDO.

Conheço do presente recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se ao preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência.

Da compulsão dos autos, depreendo que a autora/agravante, menor púbere, comprovou ser acometida de duas espécies de malformações congênita da mama, que se



A cirurgia de correção da mama tuberosa e atrofiada indicada na espécie (CIRURGIA CORRETIVA DE CÓDIGO N.º 3.06.02.033) pretende apenas garantir à paciente menor de idade, que obtenha mamas com aspecto e características dentro da normalidade, enquadrando-se portanto, no conceito de CIRURGIA REPARADORA.

Há jurisprudência pátria assente no sentido de que as cirurgias reparadoras, corretivas ou restaurativas devem ser cobertas pelos planos de saúde.

No caso, a negativa de atendimento é também ilegítima porque viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio. A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei nº 9.656/98, e nem está circunscrita às possibilidades de tratamento listadas nos instrumentos de regulamentação da ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Presentes o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado, exigidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. Ademais, inexistente perigo de irreversibilidade na concessão da medida antecipatória, pois, em caso de julgamento de improcedência da ação originária no Juízo de piso, a demandada poderá se ressarcir dos valores despendidos em virtude da cobertura da realização da cirurgia.

Agravo de Instrumento **CONHECIDO e PROVIDO**, para manter *in totum* a retro Decisão Monocrática mediante a qual, em apreciação de pedido de efeito suspensivo ativo, foi concedida a tutela de urgência pleiteada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

L. R. DE S., menor, representada por sua genitora, ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES, interpôs **AGRAVO DE INSTRUMENTO** em face da decisão prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL** n.º 0854495-37.2018.8.14.0301, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida, nos seguintes termos:

"No caso em tela vemos que o pedido da parte autora versa sobre a realização de intervenção cirúrgica por parte da demandada e que não poderia ser desfeita, impossibilitando a reversão da decisão.

Este Juízo, ao impor para a demandada a realização da intervenção solicitada, corre o sério risco de causar dano irreparável a eventual direito da mesma, tornando fraca "a probabilidade do direito", por isso se faz necessário a obtenção de mais elementos para decisão, assim INDEFIRO A LIMINAR. (DOCUMENTO ID: 11056309)."

Alega a agravante:

- (I) Ser beneficiária do plano de saúde da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, sob nº de inscrição 00010101022455000 (Safira Apartamento Empresarial);



1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805808-25.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL n.º 0854495-37.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: L. R. DE S.

REPRESENTANTE: ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES

ADVOGADO: MAURO PINHO DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA CORRETIVA DE CÓDIGO N.º 3.06.02.033. AGRAVANTE ACOMETIDA POR DEFORMIDADES CONGÊNITAS. MAMAS TUBEROSAS E ATROFIA MAMÁRIA (CID N64.2). NECESSIDADE DE CIRURGIA CORRETIVA COMPROVADA. PROBLEMAS DE ORDEM FÍSICA E PSICOLÓGICA. HISTÓRICO DE DEPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO PURAMENTE ESTÉTICA AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravante, menor púbere, comprovou ser portadora da malformação congênita denominada de “mamas tuberosas” e da patologia “atrofia mamária”, Código CID N64.2, cujo único tratamento adequado consiste em cirurgia reparadora, conforme indicada pelo médico especialista;

Embora o principal impacto dessas deformidades seja o estético, há uma indubitável e muito forte influência sobre a saúde psicológica das mulheres portadoras. Ademais, pode ser que a mulher vivencie consequências deletérias na função mamária, apresentando problemas ao amamentar, justamente devido ao formato diferente das mamas.

A lide, portanto, envolve não apenas questão física, mas também a desarmonia psicológica da paciente que já se sente incomodada com sua imagem corporal, tendo-se tornado reclusa e introspectiva, principalmente, por se tratar de uma jovem em formação, de 15 (quinze) anos, enfrentando um problema que lhe causa desconforto e constrangimento e que interfere, destarte, em diversas áreas do seu desenvolvimento. Outrossim, o laudo médico já relata histórico de depressão da jovem paciente.

No CID-10 (Classificação Internacional das Doenças), o CID N64.2, classificatório da atrofia mamária, está enquadrado no subgrupo de doenças das mamas, paradoxalmente, porém, os peritos de planos de saúde não a entendem como doença e classificam a correção cirúrgica como estética e não reparadora.





02/12/2019

Número: **0805808-25.2019.8.14.0000**

Classe: **AGRAVO DE INSTRUMENTO**

Órgão julgador colegiado: **1ª Turma de Direito Privado**

Órgão julgador: **Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE**

Última distribuição : **12/07/2019**

Valor da causa: **R\$ 10.000,00**

Processo referência: **0854495-37.2018.8.14.0301**

Assuntos: **Planos de Saúde, Práticas Abusivas**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES (AGRAVANTE)			
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (AGRAVADO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
2442961	29/11/2019 17:01	Sentença	Sentença